

1502587-93.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Alexandre Torres de Aguiar

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE EXASPERADA EM RAZÃO DA NATUREZA, QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AUMENTO DE 1/3 NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

1ª Vara Criminal

Rua Jacob Emmerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502587-93.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502587-93.2022.8.26.0536

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL FERREIRA DA SILVA

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Torres de Aguiar

Vistos.

RAFAEL FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, e c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal porque, nas circunstâncias de tempo e espaço descritas da denúncia, em ocasião de calamidade pública, mediante escalada e rompimento de obstáculo, tentou subtrair para si uma bicicleta pertencente a A.V.L.B., não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Recebida a denúncia, o acusado foi citado e ofereceu resposta à acusação.

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e uma das testemunhas arroladas na denúncia, sendo homologada a desistência manifestada pelas partes quanto à oitiva das testemunhas policiais militares. Ao final, o acusado foi interrogado.

Encerrada a instrução, realizaram-se os debates.

O Ministério Público requereu a procedência da ação, com a condenação do réu nos termos da denúncia, diante da prova produzida. Requereu a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante dos maus antecedentes do acusado e em razão de ter sido o crime praticado durante o período noturno. Pediu, ainda, o reconhecimento das circunstâncias agravantes relativas à calamidade pública e à reincidência, bem como da circunstância atenuante relativa à confissão. Pugnou, outrossim, pelo reconhecimento da tentativa e, ao final, pediu a fixação do regime inicial fechado.

A Defesa, por sua vez, deixou de requerer a absolvição do réu, diante de sua confissão. Pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal, com o afastamento da circunstância agravante relativa ao estado de calamidade pública e o reconhecimento da agravante relativa à confissão e da atenuante da confissão espontânea. Requereu, ainda, o reconhecimento da tentativa, com a aplicação da fração máxima de redução de pena e, ao final, pediu a fixação do regime inicial aberto ou, subsidiariamente, do semiaberto.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade do crime de furto descrito na denúncia está bem comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição, apreensão e entrega, pelo laudo pericial de fls. 133/139, bem como pelos demais elementos constantes nos autos.

A autoria também é certa.

Interrogado em Juízo, o acusado confessou a prática do crime descrito na denúncia. Disse que é dependente químico em recuperação e estava trabalhando em uma clínica de reabilitação, porém retornou à sua casa e tornou a usar drogas. Contou que estava com uma serra e, ao passar pelo local dos fatos, viu que ali havia uma bicicleta presa com cadeado. Disse que, quando estava serrando a corrente da bicicleta, ouviu o som de uma pessoa falando ao telefone e deixou tudo no local, evadindo-se em seguida.

Corroborando a confissão do réu, a vítima, ouvida sob o crivo do contraditório, declarou que estava dormindo quando recebeu ligação de uma pessoa do estacionamento, que informou ter surpreendido um indivíduo que lá estava serrando a corrente que prendia sua bicicleta, para subtraí-la. Disse que a polícia foi acionada e o meliante foi detido. Relatou que sua bicicleta estava presa por corrente com cadeado, que foi danificada, mas sua bicicleta não foi retirada do estacionamento. Narrou que não manteve qualquer contato com o autor do crime, pois não estava no local dos fatos e somente foi chamada ao estacionamento para reconhecimento de sua bicicleta.

Também confirmando a confissão do acusado, a testemunha Edvanio Pereira Capela, ouvida em Juízo, relatou que trabalhava como manobrista do estacionamento quando ouviu um barulho e, ao verificar, viu que um indivíduo estava ao fundo do imóvel, serrando a corrente que prendia uma bicicleta. Narrou que saiu do estacionamento a fim de ligar para a polícia e foi orientado a aguardar ao lado de fora do local. Disse que viu aquele mesmo indivíduo sair do estacionamento, pulando o muro, no mesmo momento em que a viatura estava chegando. Declarou que o meliante empreendeu fuga, mas foi detido pelos policiais. Consignou que os policiais o contataram, informando o local da abordagem, para onde rumou e onde reconheceu o acusado como o autor do crime, sem dúvidas, por sua fisionomia, por suas características físicas e suas vestes. Esclareceu que, no momento em que avistou o réu serrando a corrente da

bicicleta, olhou para o rosto dele, sendo que ele o viu e continuou praticando o crime, aparentando estar sob o efeito de alguma substância. Afirmou que há iluminação no local do estacionamento onde o réu estava e que era possível visualizá-lo. Relatou que o acusado ainda estava em posse de uma serra quando detido. Disse que, para ingressar no estacionamento, o réu havia serrado uma grade do muro, utilizando o mesmo acesso para dali evadir-se. Reconheceu o acusado em Juízo como o autor do crime.

Em face de toda a prova carreada aos autos, diante dos relatos da vítima e da testemunha presencial, os quais complementam-se e são coerentes e foram fornecidos com segurança e detalhes, corroborando a confissão do acusado, não há dúvidas em se concluir que este efetivamente praticou o delito descrito na denúncia.

Malgrado a vítima não tenha reconhecido o acusado, uma vez que sequer manteve contato com ele na fase investigatória, pois não estava presente no local dos fatos no momento do crime, o reconhecimento feito pela testemunha presencial foi exitoso em apontar o réu, sem dúvidas, como autor do crime.

Assim, embora a confissão não seja prova dotada de caráter absoluto, no presente caso, ela está em conformidade com os demais elementos coligidos aos autos, tendo sido confirmada pela prova oral produzida.

Em relação ao depoimento da vítima, assim como da testemunha presencial, em casos como o dos presentes autos, destacam-se os seguintes entendimentos jurisprudenciais:

"A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores. Se o delito é praticado na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são importantes para robustecer as declarações da vítima. Se o delito é praticado sem que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é que prepondera. A preponderação resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta inocorreu. Não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si" (TACRIM-SP - AC - Rel. Almeida Braga - JUTACRIM 100/250)

"Tribunal de Alçada Criminal - TACrimSP. PROVA - Roubo - Palavra da vítima - Valor: Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, desde que confortada por outros elementos probatórios, como o depoimento de uma testemunha, reveste-se de total importância." (TACrimSP - Ap. nº 1.157.791/5 - Araraquara - 10ª Câmara - Rel. Ary Casagrande - J. 2.2.2000 - m.v)."

Dessa forma, o crime de furto e sua autoria restaram bem demonstrados nos autos.

O crime realmente não se consumou, uma vez que o acusado não conseguiu apoderar-se da res, invertendo sua posse. Depreende-se da prova produzida que o réu foi surpreendido pela testemunha Edvanio quando estava dentro do estacionamento, serrando a corrente que prendia a bicicleta, e acabou por evadir-se do local sem nada levar consigo.

De outro lado, a qualificadora do rompimento de obstáculo foi suficientemente comprovada pelo laudo pericial de fls. 133/139.

Note-se que o exame realizado constatou que a corrente que prendia a bicicleta da vítima foi efetivamente danificada, na forma como salientado pela vítima, demonstrando, assim, a ocorrência da qualificadora.

Finalmente, o crime foi cometido durante a madrugada.

Note-se que a testemunha Edvanio ressaltou que trabalhava como manobrista do local e que surpreendeu o acusado quando ele já havia ingressado no estacionamento e já estava serrando a corrente que prendia a bicicleta da vítima, sendo inegável que a prática do crime em horário de menor vigilância sobre os bens, ocasiona, consequentemente, a maior vulnerabilidade do patrimônio.

Veja-se que a causa de aumento deve ser reconhecida, ainda que praticada contra estabelecimento comercial.

Nesse sentido, confira-se recente decisão emanada em sede de julgamento de recursos repetitivos, tema 1144:

“1. Nos termos do § 1º do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço. 2. O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto. 3. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime. 4. São irrelevantes os fatos das vítimas estarem, ou não, dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso.”

De outro lado, também recente decisão proferida pela 3ª Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, tema 1087, no julgamento do REsp nº 1.888.756/SP, afastou a incidência desta causa de aumento de pena aos furtos qualificados, fixando a seguinte tese:

“A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º).”

Por esta razão, não é caso de reconhecimento da majorante no presente caso.

Todavia, observe-se que, no v. Acórdão proferido nos autos do Recurso Especial acima aludido, destacou-se a possibilidade de consideração do repouso noturno como circunstância judicial que agravaria a pena, por se tratar efetivamente de circunstância mais grave em comparação ao delito praticado em horário diverso ou mesmo em comparação a um furto simples perpetrado durante o repouso noturno.

Veja-se:

“Deve-se registrar também que o princípio da proporcionalidade destina-se igualmente a evitar a proteção insuficiente ou deficiente dos bens jurídicos resguardados pelo Direito Penal. Ora, é evidente que a lesividade advinda do cometimento do furto qualificado durante o repouso noturno é maior que a do furto simples ocorrente no mesmo período. Assim, é razoável admitir a possibilidade de, diante das circunstâncias fáticas, a prática do furto durante o período de repouso noturno ser levada em consideração na dosimetria da pena. Em outras palavras, se a incidência da majorante no furto qualificado mostra-se excessiva, poderá ser utilizada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP). Nessa oportunidade, o órgão julgador avaliará, sob a ótica de sua discricionariedade, o elemento relativo ao espaço temporal em que a infração foi cometida, podendo, se assim considerar, analisar a circunstância judicial referente às circunstâncias do crime com maior reprovabilidade. Esse proceder possibilitaria calibrar a reprimenda de modo a atender o postulado da proporcionalidade diante do

caso concreto."

Desta maneira, restou provada a prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Passo, portanto, a dosar a pena.

Atendendo às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, observo que o acusado é detentor de maus antecedentes, conforme certidão criminal de fls. 34/36 e 37/38 e observo, também, quanto às circunstâncias do crime, que foi este perpetrado durante o período noturno, justificando-se o aumento a pena-base em 1/3, que fica fixada em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa. Considerando a situação econômica do réu, estabeleço o valor de cada dia-multa no mínimo legal, devendo ser corrigido desde a data dos fatos.

Acerca dos maus antecedentes do acusado, confira-se:

"CONSTITUCIONAL. PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. "PERÍODO DEPURADOR". REGIME PRISIONAL FECHADO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CP, ART. 33, § 3º). HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)

02. "O período depurador de cinco anos afasta a reincidência, mas não retira os maus antecedentes" (AgRg no AREsp 571.478/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 02/10/2014; AgRg no AREsp 288.127/MG, Rel. Ministro Walter de Almeida Guilherme [Desembargador convocado do TJ/SP], Quinta Turma, julgado em 06/11/2014).

03. Conquanto ao réu, condenado pela prática do crime de roubo circunstanciado (CP, art.157 § 2º, inc.II), tenha sido aplicada pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão, o fato de haver circunstâncias judiciais desfavoráveis impede a concessão, desde logo, do regime prisional semiaberto para seu cumprimento inicial (CP, art.33,§ 3º).

04. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC 314814 SP 2015/0013862-6, T5 - Quinta Turma, Ministro NEWTON TRISOTTO (Desembargador Convocado do TJ/SC), Julgamento: 19/05/2015, Publicação: DJe 25/05/2015) (grifei).

Na segunda fase da aplicação da pena, verifico que o acusado é reincidente pela prática de mesma espécie de crime, conforme certidão criminal de fls. 33, razão pela qual deve a pena ser acrescida em 1/3, ficando fixada em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

Sobre o aumento:

"PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE EXASPERADA EM RAZÃO DA NATUREZA, QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AUMENTO DE 1/3 NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada for flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A reprimenda imposta ao paciente encontra-se fundamentada em elementos concretos e dentro do critério da discricionariedade vinculada do julgador, sendo a pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da natureza, quantidade e variedade das drogas. Precedentes. 3. Possibilidade de agravamento da pena em 1/3, na segunda fase da dosimetria, em razão da reincidência específica. 4. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HABEAS CORPUS HC 305029 SP 2014/0244748-0 (STJ). 5ª T. Rel. Min. GURGEL DE FARIA. Julg. 25/11/2014. Public. 03/12/2014)

Verifico, ainda, que a infração penal foi cometida em ocasião de calamidade pública. Em que pese a vigência somente até 31 de dezembro de 2020 do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, em âmbito federal, verifica-se que o estado de calamidade pública no Estado de São Paulo, decorrente da pandemia do COVID-19, foi reconhecido por meio do Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020, que ainda se encontra em vigência diante de sucessivas prorrogações. Portanto, em âmbito estadual, mantiveram-se vigentes as normas referentes ao reconhecimento do estado de calamidade pública. Destaque-se, ainda, que, o uso de máscaras de proteção facial em espaços de acesso público localizados no território estadual, como medida para conter a disseminação da COVID-19, conforme disposto no Decreto nº 65.897 de 30 de julho de 2021 do Estado de São Paulo, permaneceu vigente até o dia 08 de setembro de 2022, quando tais medidas foram liberadas por meio do Decreto nº 67.096. Saliente-se, ainda, que, embora sem revogação expressa do Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020, que reconheceu o estado de calamidade pública neste estado, deve-se considerar que as medidas de contenção contra o avanço do novo coronavírus permaneceram vigentes até 08 de setembro deste ano de 2022 quando, por parecer do Conselho Gestor da Secretaria de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde do Estado de São Paulo, verificou-se possível esta flexibilização dos regramentos.

A agravante tem caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência. De qualquer forma essa circunstância não pode ser ignorada, pois o isolamento social e a quarentena, em razão da pandemia, facilitam a prática do crime. Impõe-se, portanto, o aumento de pena pelo reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

Contudo, reconhecida também a circunstância atenuante da confissão espontânea, ficam estas compensadas.

Na última fase do cálculo da pena, reconhecida a tentativa e considerando o iter criminis percorrido, considerando que o acusado ingressou no estacionamento e foi surpreendido serrando a corrente de segurança da bicicleta da vítima, mas observando-se que ele acabou por evadir-se do local sem nada levar consigo, a pena é reduzida de 1/2, resultando em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 08 (oito) dias-multa, no valor já estabelecido.

À míngua de outras causas modificadoras da pena, torno definitiva a reprimenda acima estabelecida.

Fixo ao acusado o regime fechado como regime inicial do cumprimento da pena, diante de sua reincidência específica e das circunstâncias judiciais negativas, na forma como já exposto.

Pelos mesmos motivos, não estão presentes os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal, de modo que deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos sendo, pela mesma razão, também incabível o sursis.

Finalmente, não há se cogitar da aplicação imediata do disposto no §2º do artigo 387 do Código de Processo Penal nesta seara, vale dizer, sem elementos concretos a respeito dos seus comportamentos no cárcere, a recomendar a prudência e o bom senso que a questão relacionada à detração penal seja analisada por primeiro pelo Juízo das Execuções.

A lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o Código Penal e não o Código de Processo Penal. A progressão de regime vem, por sua vez, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua

especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada a progressão, imprescindível que sejam analisados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o do Juízo das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.

Nesse sentido:

"Apelação - Tráfico de entorpecentes - Materialidade e autoria bem demonstradas - Testemunho dos agentes policiais, sob o crivo do contraditório, ratificando a prova administrativa - Ré confessa, ademais - Não incidência do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, uma vez que não preenchidos os requisitos subjetivos - Precedentes - Pena de multa que se corrige - Mínimo erro material do r. juízo em detrimento da apelante - Regime fechado justificado - Impossibilidade de substituição da física por restritiva de direito - Detração - Matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais - Recurso desprovido, com observação." (TJSP - Ap. Nº 0003591-97.2014.8.26.0577 - 4ª Câmara - Rel. Ivan Sartori - J. 28.04.2015 - grifei)

Deve-se ressaltar, ainda, que a detração neste momento processual causaria a supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu RAFAEL FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, às penas de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, incidente a correção monetária, por infração ao disposto no artigo 155, parágrafo 4º, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, e c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal.

Nego ao réu o direito de apelar desta em liberdade, estando presentes os requisitos para a prisão preventiva. O acusado é reincidente e as circunstâncias judiciais lhe são negativas. A reiteração de condutas criminosas evidencia a dificuldade do réu em aceitar a ordem legal estabelecida, pois não hesita em reiterar a prática delitiva, colocando em maior risco a ordem social.

Finalmente, não há qualquer alteração da situação fática ou jurídica que justifique a reconsideração da decisão que decretou a custódia cautelar no presente feito, mormente no momento em que foi proclamado culpado em primeiro grau de jurisdição.

Portanto, verifico que ainda estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo de rigor manter a prisão preventiva, cumprindo-se, outrossim, o disposto no parágrafo único do artigo 316 do mesmo diploma legal.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Ausente demonstração mínima dos integrais prejuízos sofridos pela vítima, bem como pela ausência de pedido nesse sentido na denúncia, deixo de condenar os réus nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, sem prejuízo do direito de reparação do ofendido a ser perseguido na esfera cível.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Vicente, 18 de novembro de 2022.

ALEXANDRE TORRES DE AGUIAR
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA